

RECURSO CÍVEL Nº 5006497-27.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: HAGAMENON NUNES MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (PSS) - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDPST - SERVIDOR ESTATUTÁRIO ATIVO QUE PRETENDE A RESTITUIÇÃO DO PSS SOBRE A PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À APOSENTADORIA - JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO POSTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/03 E 47/05 - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso inominado da parte autora, de modo a excluir a parcela da Gratificação de Desempenho que não será incorporada aos proventos de aposentadoria da parte autora da base de cálculo do PSS, bem como a restituir à parte autora os valores descontados àquele título, desde a prescrição quinquenal. Os valores atrasados deverão ser acrescidos da taxa SELIC desde cada desconto, a título de consectários legais. Condene a União em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juiz Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5006497-27.2024.4.02.5103

510014833564 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5006497-27.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: HAGAMENON NUNES MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Em suma, a pretensão da parte autora consiste na condenação da União, para que se abstenha de descontar a contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor Público Federal - PSS sobre a parte da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST que não incorpora à aposentadoria, assim como à repetição do indébito dos valores recolhidos a esse título que incidiram sobre a pontuação da aludida gratificação, desde agosto/2019, devidamente atualizado monetariamente.

O Juízo de origem julgou **improcedentes os pedidos**.

Em suas razões recursais, a parte autora reitera os termos da inicial, visando excluir da base de cálculo da contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor Público Federal - PSS de parte da gratificação de desempenho não incorporável.

É o relatório. Decido.

VOTO

No mérito, a jurisprudência dominante, discutida em várias instâncias ordinárias, é no sentido de **afastar da base de cálculo parcelas não incorporáveis aos futuros proventos do servidor**, permanecendo a exação para o PSS sobre verbas pagas de forma permanente ao contribuinte e incorporáveis. Neste sentido, a título de exemplo, a questão foi resolvida pelo STJ

em caso análogos aos presentes, em sede de **recurso repetitivo, desde fevereiro de 2014** (REsp 1.230.957/RS, DJe 18/03/2014), no que tange a não tributação de um terço constitucional, seja para férias indenizadas, seja para férias efetivamente gozadas. Vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO VIOLAÇÃO. 1. "A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na linha de orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, revendo seu posicionamento, firmou compreensão segundo a qual não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, verba que detém natureza indenizatória por não se incorporar à remuneração do servidor para fins de aposentadoria" (Pet 7.296/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 10/11/09). Precedentes: AgRg no AREsp 85.096/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2012; AgRg no REsp 1415775/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 09/03/2015; EAg 1200208/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 20/10/2010; AgRg no AREsp 223.988/PE, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 09/05/2013. (...) 3. Agravo regimental da Fazenda Nacional desprovido. (AgRg no REsp 1056203/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 06/04/2015)

RECURSO ORDINÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGENS QUE NÃO SE INCORPORAM AO VENCIMENTO DO SERVIDOR, QUANDO DA PASSAGEM PARA A INATIVIDADE REMUNERADA, BEM COMO SOBRE AS VANTAGENS INDENIZATÓRIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1(...) 2. Na interpretação da Lei nº 9.783/99, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a contribuição previdenciária não incide sobre as vantagens não incorporáveis ao vencimento do servidor, quando de sua passagem para a inatividade remunerada, bem como sobre as vantagens cujo cunho é meramente indenizatório. 3. Recurso parcialmente provido. ..EMEN: (ROMS 200401038387, PAULO MEDINA, STJ - SEXTA TURMA, DJ DATA:03/10/2005 PG:0033:.)

O Supremo Tribunal Federal, mais de uma vez, já se manifestou no sentido de que adicionais pagos que não incorporem aos proventos recebidos pelo servidor público na inatividade não devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária (v.g., RE 438.320, Rel. Min. Marco Aurélio; AI 516.499, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 417.089, Rel. Min. Carlos Britto; AI 603537, Rel. Min. Eros Grau). Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da contribuição previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 603537 AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ 30/03/2007)

Por fim, a **Turma Nacional de Uniformização já analisou a matéria e entendeu pela tributação apenas da parcela do adicional incorporável** - PEDILEF nº 0006275-98.2012.4.01.3000, Rel. Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, j. 06/08/2014, DOU 03/10/2014, transcrevo excerto:

"15. A partir da leitura da regra referida é possível inferir que não há uma incorporação plena da GACEN para os proventos da inatividade. O precedente, que adiante é transcrito, tornou-se paradigmático para todo nosso ordenamento jurídico, e foi proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 434.754/MA, julgado em 26/04/2004, da Relatoria do Ministro Cezar Peluso, o qual o propósito, alude à decisão administrativa proferida pela mesma Suprema Corte em exato sentido: (...) 16. Do cotejo, entre a situação em exame, onde há uma incorporação apenas parcial da gratificação percebida, com o posicionamento pacificado na jurisprudência do augusto Supremo Tribunal Federal, tem-se que seria incabível a incidência do tributo sobre o percentual não incorporável, pelo que, no ponto, assiste razão ao juiz sentenciante, que assim o declarou. Considerando que o particular não se irressignou quanto a isso e que o Pedido de Uniformização foi apenas a Fazenda Nacional, entendo que, neste processo, também se poderia utilizar tal fundamento para negar provimento ao incidente." (in, <https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/>). - grifo meu.

A questão, portanto, é verificar qual a parcela incorporável desta gratificação.

A possibilidade de opção pela incorporação à aposentadoria trazida pela Lei nº 13.324/16 (a justificar a incidência do PSS) e quem dela pode se valer, já foi amplamente explanada nestes autos nas várias decisões proferidas e supra rememoradas.

Essencialmente, o direito a incorporação da gratificação seria reservado aos servidores **ATIVOS** que contassem **com mais de 5 anos de contribuição** (60 meses) e se enquadrassem nas hipóteses das **emendas constitucionais 41/03 e 47/05, o que pressupõe ingresso até 31/12/2003, data da publicação da EC41 e mais antiga dentre aquelas dirigidas aos servidores pelas emendas:**

*Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, **até a data de publicação desta Emenda**, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.*

(...)

*Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo **art. 40 da Constituição Federal** ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, **que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda** poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no **§ 5º do art. 40 da Constituição Federal**, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:*

O direito de opção, portanto, fica restrito àqueles que ingressaram no serviço público até 31/12/2003 (mediante requisitos) ou que já tivessem condições de se aposentar naquela data pelas regras anteriores a reforma da EC41 mas se mantiveram no exercício do cargo público.

Segundo as fichas financeiras anexadas, a parte autora é servidor público **ATIVO** do Ministério da Saúde com ingresso no serviço público em **abril de 2006**, após o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que alterou o parágrafo oitavo do art. 40 da Constituição Federal e pôs fim a paridade entre servidores ativos e inativos. **A data de ingresso do autor consta da consulta ao Portal da Transparência, a qual o autor anexou na fl. 3 da inicial (evento 1, INIC2),** ou seja, **NÃO PODE SE VALER DA OPÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS.**

Desta feita, pode-se concluir que o autor não poderia optar por incorporar a GD a sua aposentadoria e, por isso, à luz da Lei de 2016, poderia, a priori, excluir a incidência do PSS sobre tal verba pois se viesse a incorporá-la teria de contribuir para a mesma.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO** ao recurso nominado da parte autora, de modo a **excluir a parcela da Gratificação de Desempenho que não será incorporada aos proventos de aposentadoria da parte autora da base de cálculo do PSS,** bem como a restituir à parte autora os valores descontados àquele título, **desde a prescrição quinquenal.** Os valores atrasados deverão ser acrescidos da taxa SELIC desde cada desconto, a título de consectários legais. Condene a União em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juiz Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. É como voto.